

1500250-38.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... que os acusados realmente se dedicavam ao tráfico, em razão da quantidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico em larga escala.

Em relação ao acusado Fernando, os guardas civis municipais afirmaram que viram o momento em que ele recebeu objeto do corréu Gustavo, que estava no interior do imóvel e, após a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500250-38.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-38.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO HENRIQUE GARCIA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Fernando Henrique Garcia e Gustavo Gabriel Dias foram denunciados e estão sendo processados, porque no dia 09 de julho de 2021, por volta das 13h20min, na Rodovia SP 342, Km 180, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de praças públicas e de locais especialmente protegidos pela lei, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com peso bruto total de 72g (setenta e dois gramas) e 104 (cento e quatro) pedras de "crack", que contém o princípio ativo da cocaína, com peso bruto total de 32,64g (trinta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, e o faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram notificados (fls. 187 e 189), apresentaram defesa prévia (fls. 202/210 e 251/253) e a denúncia foi recebida pela decisão de fls. 259/260.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados. O representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação dos acusados nos termos descritos pela denúncia.

A defesa do acusado Fernando requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu, sustentando que ele possuía apenas 4 porções de 'crack' e que não se dedicava ao tráfico de drogas. Alternativamente, pretende a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da lei n. 11.343/06.

A defesa do acusado Gustavo requer sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Requer, ainda, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, III da lei antidrogas, e a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 11/12); pelo laudo pericial do local (fls. 177/182); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 147/149 e 150/152), comprovante de depósito de numerário apreendido (fls. 156) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Everton Rodrigo dos Santos disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistou o acusado Fernando no portão da residência, do lado de fora, recebendo algo da pessoa que estava dentro do imóvel. Então, Fernando foi abordado e em suas mãos havia um invólucro plástico com 26 pedras de crack. Na sequência, abordaram Gustavo do lado de dentro do portão, indivíduo este já conhecido da guarnição, o portão encontrava-se trancado, porém, de pronto Gustavo disse perdi, destrancou o portão e dentro do quintal apontou aos Guardas Municipais onde estava o restante das drogas, mais precisamente, dentro de um pacote de arroz. No local apontado foram encontradas porções de maconha e pedras de crack. Após, Gustavo mostrou onde estava balança de precisão e R\$ 110,00 (cento e dez reais) em dinheiro. Disse que o portão da residência de Gustavo estava fechado e ele franqueou o ingresso. Já havia abordado os acusados, mas nada ilícito apreendido com eles nas ocasiões anteriores.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Carlos Cezar Borges.

O acusado Fernando Henrique Garcia disse que a droga apreendida foi comprada pelo interrogando em outro local para seu consumo pessoal. Os guardas lhe perguntaram se possuía droga e com o interrogando havia apenas 4 porções de 'crack'. Nega que possuísse 26 pedras de 'crack'. Não conhecia o corréu e não frequentava a casa dele. Nunca foi processado pelo crime de tráfico de drogas.

O acusado Gustavo Gabriel Dias disse que o corréu lhe afirmou que havia adquirido 4 pedras de 'crack' em outro local. Disse que não entregou nenhum objeto ao corréu Fernando. Afirma que guardava 25 porções de maconha e 3 kits, cada um contendo 26 porções de 'crack', para terceira pessoa, cujo nome prefere não declinar. Os guardas civis apreenderam R\$110,00 em dinheiro, que pertenciam a sua esposa. Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que os acusados realmente se dedicavam ao tráfico, em razão da quantidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico em larga escala.

Em relação ao acusado Fernando, os guardas civis municipais afirmaram que viram o momento em que ele recebeu objeto do corréu Gustavo, que estava no interior do imóvel e, após a abordagem, constataram que se tratava de 26 porções de 'crack'.

A versão do acusado Fernando no sentido de que trazia consigo apenas 4 porções de 'crack', as quais teria adquirido em outro local e seriam destinadas a seu consumo pessoal, está isolada nos autos e não encontra respaldo na prova oral produzida, sendo que não comprovou nenhum elemento concreto que demonstre interesse dos guardas civis em prejudica-lo.

Aliás, é sintomático o fato de que, no interior do imóvel de Gustavo, foram apreendidos outros 3 kits, cada um contendo exatamente 26 porções de 'crack', mesma quantidade apreendida com Fernando, corroborando, assim, a narrativa dos guardas civis no sentido de que Fernando recebeu o kit, com 26 porções de 'crack', da pessoa que estava no interior do imóvel e que, em seguida, verificaram tratar-se de Gustavo.

A versão de Fernando no sentido de que seria apenas usuário de drogas não se harmoniza à quantidade apreendida, que é expressiva e o agente não comprovou condição financeira para adquirir as 26 porções de 'crack' para seu consumo pessoal.

Quanto ao acusado Gustavo, anoto que ele confessou que guardava as drogas para terceira pessoa, cujo nome preferiu não declinar, de modo que a autoria do crime de tráfico de drogas é incontestado em relação a ele.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que os acusados traziam consigo e guardavam quantidade expressiva de drogas acondicionadas de forma fracionada, devem ser dados como incursos naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Como já destacado, não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que os próprios acusados disseram que não tinham nada contra os agentes, não se vislumbrando nenhum indício para imputarem falsamente o crime aos acusados. Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado Gustavo, pois guardava drogas diversas e, uma delas ('crack') em quantidade expressiva (78 porções) e de efeitos especialmente deletérios, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa.

Por sua vez, o acusado Fernando ostenta maus antecedentes, em razão da condenação nos autos n. 741-12.2009 e 6097-27.2009 (fls. 314), de modo que estipulo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, o acusado Gustavo é menor de 21 anos de idade, devendo ser reconhecida a atenuante, com o retorno da pena ao mínimo legal.

Ainda em segunda fase, o acusado Fernando é reincidente, em razão da condenação imposta nos autos n. 167-04.2018 (fls. 313), de modo que aumento sua pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de fls. 177/182 revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existe campo de ensino, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e

"Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, majoro a pena de ambos os acusados em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa, para o acusado Gustavo, e pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e pagamento de 793 dias multa, para o acusado Fernando.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em benefício do acusado Fernando, pois ostenta Maus antecedentes e é reincidente.

O acusado Gustavo também não deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois ostenta outro processo em andamento por fato análogo, isto é, pela prática de tráfico de drogas (autos nº 1500130-92.2021 - fls. 318), fato ocorrido noventa dias antes do fato aqui apurado. Vale anotar que, apesar da inexistência de condenação criminal naquele feito nº 1500130-92.2021 - fls. 318, pode-se verificar que o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória no dia 10 de abril de 2021 e, inobstante tal fato, foi preso pelo fato aqui apurado no dia 9 de julho de 2021, demonstrando sua dedicação a atividades criminosas e, por isso, não fazendo jus à aplicação do benefício na presente fase de dosimetria da pena.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

Em relação ao acusado Fernando, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois ostenta Maus antecedentes e é reincidente.

Quanto ao acusado Gustavo, as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, de modo que, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos para qualquer dos acusados, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO (i) Fernando Henrique Garcia à pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 793 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e (ii) CONDENO Gustavo Gabriel Dias à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da

Lei nº 11.343/06.

Os réus responderam ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando-se que Gustavo foi beneficiado com a liberdade provisória 90 dias antes de ser preso pelo fato aqui apurado e, apesar disso, tornou a se envolver com o tráfico de drogas, guardando quantidade expressiva de drogas diversas, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública.

Quanto ao acusado Fernando, anoto que ele ostenta condenações criminais diversas com trânsito em julgado, sendo, inclusive, reincidente, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Recomendem-se na prisão, com expedição de ofícios.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois os acusados não atingiram o lapso temporal para eventual progressão de regime. Expeçam-se certidões de honorários aos patronos dativos nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Decreto o perdimento do numerário apreendido em posse do acusado Fernando, pois não demonstrada a origem lícita e porque consequência lógica da condenação imposta.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 03 de junho de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA